

1501065-21.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... as denúncias recebidas sobre o tráfico de drogas praticado pelo denunciado, somada à quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, adquiridas de pessoa até o momento não identificada, além de balança de precisão (com resquícios de entorpecente de natureza diversa da apreendida nos autos - indicando a dedicação ao tráfico de drogas - fls. 95/97) e embalagens para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501065-21.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501065-21.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL CABRERA VERCULINO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MIGUEL CABRERA VERCULINO DA SILVA, qualificado à fl. 06, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Sebastião Henklain, nº 270, Jardim Ivanira, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo e guardava droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em: (i) 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 5,21g (cinco gramas e vinte e um centigramas - lacre nº 0033957); (ii) 05 (cinco) porções da mesma substância entorpecente, com peso líquido total de 386,54g (trezentos e oitenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas - lacre nº 0033958), conforme boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/13, fotografias de fls. 26/29, auto de constatação preliminar

de substância entorpecente de fls. 14/15, laudos periciais nos objetos apreendidos às fls. 83/85, 95/97 e 105/107 e exames químico-toxicológicos definitivos às fls. 89/94. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de maconha acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a trazer uma porção consigo e manter cinco em depósito em sua residência, com vistas a comercializá-las ilicitamente. No dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o MIGUEL e um rapaz e, ante os prévios informes indicando que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas, resolveram abordá-los. Em revista pessoal, constataram que o imputado trazia consigo, no bolso da bermuda, uma porção de maconha; nada de ilícito foi localizado com o outro rapaz, identificado como Thiago Cabrera Parra Soares. Em revista na residência de MIGUEL, após a entrada ser franqueada por sua genitora, os policiais militares localizaram, no quarto dele, em uma gaveta do guarda-roupas, dois aparelhos de telefones celulares, balança de precisão, faca, dinheiro sem comprovação de origem lícita, plástico filme e, ainda, dentro de uma bolsa pequena, estavam guardadas 05 (cinco) porções de maconha, das quais três estavam fracionadas e prontas para a comercialização e duas estavam na forma "bruta". Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando as denúncias recebidas sobre o tráfico de drogas praticado pelo denunciado, somada à quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, adquiridas de pessoa até o momento não identificada, além de balança de precisão (com resquícios de entorpecente de natureza diversa da apreendida nos autos - indicando a dedicação ao tráfico de drogas - fls. 95/97) e embalagens para acondicionar drogas fracionadas para a venda, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 134/139), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 143), o despacho de fls. 179/183, de 28 de janeiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 219/220), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 219/220), arguiu preliminarmente, a ilicitude da prova angariada aos autos, vez que o ingresso de policiais no interior do imóvel residencial do autuado, sem o correspondente mandado de busca e apreensão e sem autorização do réu, foi furtiva, devendo toda a prova colhida no local do delito ser declarada nula e o réu absolvido nos termos do artigo 386, inciso VII, CPP. Requer ainda a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ante a dúvida da destinação da droga apreendida. Em caso de uma eventual condenação, que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, em razão de os requisitos do artigo 59, do Código Penal lhe serem favoráveis, da sua primariedade, e seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, substituindo-se a pena corporal por restritiva de direitos, eleito o regime aberto para cumprimento de pena em caso de revogação, bem como o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade, decorrente de violação ao domicílio, entendo que não há como ser acolhida, visto que se tratando de flagrante delito, tendo sido o réu flagrado com considerável quantidade de droga, aliada a inúmeras denúncias imputando ao réu a prática de tráfico de drogas no local, o que ensejou a efetiva abordagem quando o réu trazia consigo maconha já embalada para venda, conforme objetos e petrechos encontrados em sua residência que denotam estar naquele local para realizar o comércio da droga, e com eficiência que lhe é notória, a Polícia Militar logrou encontrar grande quantidade da droga escondida no seu guarda-roupas, além de uma faca e plástico filme, com resquícios da mesma droga, ou seja, é crível que ele tenha acabado de fracionar o tijolo encontrada na sua residência e saiu para a venda de pouca quantidade, é dessa forma que quase a maioria dos traficantes agem na região, sendo notória tal prática e já conhecida pela polícia em geral, culminando com a prisão do acusado, não se mostrando possível alegar a referida garantia constitucional.

No caso dos autos, tais circunstâncias mostram-se suficientes para o afastamento de

qualquer alegação de nulidade da prova.

Até porque havia fundadas e sérias razões para se suspeitar do réu, e que, por fim, com a autorização da sua genitora e de quem mais morava ou estava naquela residência no momento da chegada da Polícia, que é incontestante diante da prova dos autos, encontram uma grande quantidade de drogas escondida, evidenciam sobremaneira a traficância no local, graças à rápida e eficaz atuação da Polícia no combate ao tráfico de drogas.

É conveniente ao réu e a sua defesa, perante o Juízo, dizer que não houve qualquer autorização para a entrada da Polícia Militar na residência, sem trazer qualquer prova da sua afirmação, ao contrário, os Policiais Militares foram uníssonos em afirmar que a genitora do réu autorizou o ingresso da equipe em sua residência, até porque não mencionou, em momento algum que não houve autorização ou que não há provas dessa autorização, pois cabe ao réu provar e trazer provas para confirmar suas alegações.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. RECORRENTE ABORDADA EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE FOI ENCONTRA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS, ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES EM DOMICÍLIO ALHEIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade, pela ausência de mandado de busca e apreensão, insta consignar que tanto a jurisprudência desta Corte, como a do eg. Supremo Tribunal Federal, firmaram o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como é o delito de tráfico de entorpecentes mostra-se prescindível o mandado judicial, em caso de flagrante, como na hipótese. III - No caso, sub examine, no qual se alega a ocorrência de irregularidade face a ausência de mandado judicial, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a atuação dos agentes policiais no sentido de ingressar em domicílio alheio teve como elementos precursor e a abordagem realizada em via pública, "[...]momento que encontraram pequena porção de substâncias entorpecentes", bem como informação acerca da existência de mais droga no local em que ela reside, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. IV - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. V - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva da ora Agravante, porquanto, consoante se deduz dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, tendo o magistrado primevo ressaltado na decisão objurgada que ela "já responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas (0007559-75.2018.805.0191), onde foi concedida liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão", circunstância que indica a periculosidade concreta da agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC140.998/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,

julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Segundo o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020).

É que quando se trata de crime permanente, como o porte de arma e de munição e no tráfico de drogas, não há a invasão preconizada, pois a flagrância protraí-se no tempo, podendo, a qualquer momento, o policial prender o réu. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. Não existe, pois, violação de preceito constitucional, art. 5º, XI, da Carta Magna, ou legal (art. 303 do Código de Processo Penal).

A prisão foi feita em conformidade com os ditames legais. O direito em análise não é absoluto, quando há flagrância, pode-se agir, caso contrário, outro tipo de violação poderia ocorrer, até mais grave. "Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio" (HC 208957/SP- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) - J. 6.12.2011 - DJe 19.12.2011). Cf., ainda, HC 101628/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) - J. 21.10.2008 - DJe 10.11.2008; HC77489/AM - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J. 12.2.2008 - DJe 17.3.2008; HC 40056/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Hamilton Carvalhido - J. 30.6.2005 - DJ 05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO- 5ª do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Gilson Dipp - J. 28.4.2004 - DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP - 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - J. 1.4.2004 - DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406).

O C. Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Tal matéria, todavia, foi suscitada novamente e em reexame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça e que no julgamento de Habeas Corpus nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no dia 2/3/2021, decidiu: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO

CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. [...] 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente [...] (HC 598.051/SP. MATÉRIA CRIMINAL. Relator Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 6ª Turma. JULGADO: 02/03/2021. Publ. 15/03/2021).

O Min. Relator Rogério Cruz justificou a decisão da turma em que, somente fundadas razões e desconfianças dos agentes do estado, não são suficientes para o ingresso sem mandado judicial na casa do suspeito, e além disso “deve haver documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado, seja toda registrada em áudio e vídeo, de maneira a não deixar dúvidas quanto a legalidade da ação estatal e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado”. Entretanto, tal matéria foi objeto de análise em sede de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e teve como Relator Min. Alexandre de Moraes, que decidiu de acordo com a repercussão geral daquela Corte quando descreve “o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, conseqüentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Também ponderou que a TESE é de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”.

Sem mais aprofundamento sobre a matéria e esgotada toda e qualquer discussão acerca do tema, merece então trazermos a parte final do julgamento que ocorreu no dia 02/12/2021, pelo Ministro Alexandre de Moraes, conforme segue:

“Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa)[...].”

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e

materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/13; fotografia de fl. 16; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 14/15; pelas fotografias de fls. 26/29; pelo laudo químico toxicológico de fls. 89/91 e 92/94, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0033958 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) encerrando 5 porções de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, destes, 3 apresentavam-se embalados em plástico filme. Massa Bruta e/ou Quantidade: 404,96 grama(s) - quatrocentos e quatro gramas e noventa e seis centigramas. Massa Líquida: 386,54 grama(s) - trezentos e oitenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas. Item Único (Acondicionado sob o lacre 0033957 ) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 11,22 grama(s) - Onze gramas vinte duas centigramas. Massa Líquida: 5,21 grama(s) - Cinco gramas vinte uma centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial de objeto de fls. 83/85 - Item Único (Acondicionado sob o lacre 001478) Descrição: Descrição: 1 (uma) faca de mesa, usada, em regular estado de conservação, da marca SIMONAGGIO, dotada de uma lâmina em metal inoxidável pontiaguda, de gume serrilhado, sendo o cabo constituído de plástico preto. Mede aproximadamente 215 milímetros de comprimento total e sua lâmina mede cerca de 113 e 11 milímetros de comprimento e de largura máximas, respectivamente. O objeto pode ser utilizado para fracionar substâncias entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e laudo pericial de fls. 86/88, tratando-se de - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0014778 ) Descrição: 1 (um) rolo de filme de PVC transparente, usado, sem marca aparente, medindo aproximadamente 40 e 5 centímetros de largura e de diâmetro, respectivamente. O material pode ser utilizado para embalar substâncias entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial de fls. 95/97, tratando-se de: Item Único (Acondicionado sob o lacre 0014776 ) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando uma balança de bolso, com inscrição "TOMATE", usada, em regular estado de conservação, confeccionada em material sintético prata e azul. Apresentava prato próprio para acomodar objetos ou substâncias e tela digital. Suas dimensões correspondem aproximadamente a 15,00 cm de comprimento x 7,00 cm de largura x 1,50 cm de espessura. Não se encontrava alimentada por pilhas. Inserindo pilhas na balança a mesma não se encontrava operante. A peça foi submetida à lavagem química para análise. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial de objeto de fls. 105/107, tratando-se de Item Único (Acondicionado sob o lacre 0014779) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando uma bolsa, usada, de material sintético e cor marrom, com alça preta, com dimensões de alt. 17 cm, larg. 15,5 cm e prof. 5 cm, constituída de dois compartimentos com zíper, apresentando resquícios/sujidades. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial em aparelhos celulares de fls. 98/104; além da prova oral carreada para os autos.

A testemunha PM André Luiz de Almeida Cristofano, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento, tendo recebido várias denúncias de tráfico na residência de Miguel, e se depararam com o réu próximo a sua casa, na esquina com um amigo, resolveram aborda-los. Em revista pessoal com o Miguel foi encontrada uma certa quantidade de maconha, dizendo ele que era para seu uso. Deslocaram-se até a residência e em contato com a genitora, nos franqueou a entrada e em revista no quarto do Miguel, na gaveta do guarda-roupas, foi localizada mais 400 gramas de maconha, balança e dinheiro, três dessas porções já embaladas para venda, papel filme e faca também foram encontradas. Foi acionado o canil pois também tinha denúncias que na mata próxima havia mais drogas enterradas, todavia nada foi localizada, sendo conduzido ao plantão de polícia.

A testemunha PM. Rodolfo das Neves, sob o crivo do contraditório, declarou que nesta data a equipe estava em patrulhamento preventivo devida a altas denúncias de tráfico no local onde o réu reside. Se depararam com o réu e um parente caminhando, e ao aborda-los, com Miguel foi localizada uma grande quantidade maconha que ele disse ser para seu próprio uso. Deslocaram-se até sua casa, sua mãe autorizou a entrada da equipe, e como havia muitas denúncias de tráfico naquele local, fizeram uma busca detalhada e no guarda-roupas foi localizado meio tijolo de maconha. Posteriormente, acionaram o canil e pela mata, segunda denúncias ele enterrava naquele local, porém nada de ilícito foi encontrado.

A testemunha Thiago Cabrera Parra Soares, declarou que é primo de Miguel Cabrera, prestando depoimento sem compromisso legal, apenas como informante. Sobre os fatos disse que não tinha conhecimento, estava com ele no dia da abordagem, mas não sabia de nada. Ocorreu uma abordagem normal, e até então não sabia da ocorrência, ficou sabendo apenas na Delegacia. Não sabia de que Miguel era traficante, mas que ele fumava de vez em quando sim. Sabe que ele é usuário de maconha. Acompanhou a polícia até a casa, mas ficou do lado de fora, tomaram seu celular e não lhe deixaram entrar. Tinha sua mãe, a mãe do réu, sua avó que é cadeirante, sua tia e o padrasto dele.

Em seu interrogatório, o réu Miguel Cabrera Virculino da Silva, declarou que nunca foi preso e nem processado anteriormente. Sobre os fatos disse que prefere ficar em silêncio.

Há que se consignar que também invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio quando ouvido em sede inquisitiva.

Encerrando-se a instrução processual.

Diante de toda a prova produzida nos autos, e do silêncio do réu, que preferiu não dar sua versão dos fatos, embora seu silêncio não possa ser tido com uma confirmação dos fatos, na realidade, estes ocorreram conforme descrito na denúncia, e que foram detalhados pelos Policiais Militares André Luiz e Rodolfo, que de forma coesa e harmônica, relataram com vigor como os fatos se passaram, desde a abordagem do réu, juntamente com seu primo, a testemunha Thiago Cabrera, quando em revista pessoal localizaram uma considerável quantidade de maconha em suas vestes, e diante da inúmeras denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no local, mais precisamente na residência do réu, para se dirigiram e com autorização da genitora do réu, ingressaram no imóvel e no quarto dele, em uma gaveta no guarda-roupas, lograram encontrar, dentro de uma bolsa pequena, cinco porções de maconha, três já fracionadas e prontas para a venda e duas estavam na forma de tijolo.

O informante Thiago Cabrera, que é primo e também foi abordado na diligência, nada soube responder acerca da droga encontrada, balança, faca e plástico filme com resquícios de droga, além de dinheiro, apenas se limitando a dizer que nada sabia, tomou conhecimento somente na Delegacia e sabe que Miguel é usuário de maconha. Ao final de seu depoimento, em resposta aos questionamentos do d. Defensor Público se havia mais alguém na residência no momento da chegada da equipe policial, disse que estava a mãe do réu, sua mãe, sua avó que é cadeirante, sua tia e o padrasto do réu.

Somente essa fala é suficiente para jogar por terra a arguição de nulidade feita pelo Defensor, já que onde havia várias pessoas, não há relatos em nenhum momento dos autos que houve sequer tumulto na ação policial, pois, por óbvio veio a durar um tempo razoável, pois foi ainda, acionado o canil da Polícia Militar para tentar

localizar drogas enterrada numa mata próxima, segundo denúncias anônimas. Poderia ter a defesa, trazido aos autos qualquer dessas testemunhas presenciais para afirmar suas alegações, demonstrando ao menos um bom senso em fazer afirmações que sequer consegue provar.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Convém anotar, ainda, que o crédito na palavra de policiais não depende de seus depoimentos serem confirmados por pessoas fora de seus quadros, até porque, sabido é, pessoas do povo ou mesmo próximas, não se dispõem a depor contra pessoas envolvidas em ocorrências policiais, por constrangimento ou medo de represálias. Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar, ou por não ter sido arroladas outras pessoas que estavam no local dos fatos.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Com efeito, a quantidade de droga apreendida pertencente ao réu (porções de maconha

e uma delas, a maior pesando 386,54 gramas). O laudo pericial no plástico filme encontrado na residência do réu, é idêntico ao que embalava as porções encontrada no bolso do réu, além da faca e da balança de precisão, e que a perícia (fls. 86/88, 83/85, 95/97, respectivamente) revelou haver resquícios da mesma droga encontrada na residência e na posse do réu (maconha). Além das drogas, da faca, do rolo de plástico filme e da balança, foram apreendidos R\$ 70,00 (setenta reais), bem como dois telefones celulares, que não tinham nenhuma informação, nenhum aplicativo instalado e nenhuma conta registrada, o que denota tratar-se de objetos ilícitos, entretanto, não foi apurado nos autos, além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Ademais, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 26/29, corroborada pelos depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Também ficou comprovado nos autos, a certeza da denúncia anônima recebida pelos agentes policiais, informando que no local dos fatos, estaria comercializando drogas.

Denota-se in casu, que a notícia-crime, em si, reflete a indignação da população, de vizinhos e transeuntes que passam pelo local, acerca da traficância realizada pela acusada, fato este que ficou demonstrado com a apreensão da droga elencada nos autos.

Nesse sentido:

"Não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas, tem sido de suma importância para a repressão ao crime. Tanto é que foram criados diversos "disque-denúncias". Tendo a Polícia Judiciária o dever de apurar as infrações penais que chegam a seu conhecimento, mesmo que decorrentes de comunicações anônimas." (TJSP -Apelação nº 0064980-49.2013.8.26.0050. Rel. Paulo Rossi, j. em 19.02.2014)

Obtemper-se que no caso trazido à liça, o acusado foi surpreendido pelos policiais no momento da prática delitiva, o que constitui, desta forma, a evidência do fato punível, a certeza visual do crime.

Neste prisma, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca, é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5a ed., 11/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido: PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento: 59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12a Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)" (TJSP Apelação nº 01112349.3/7-0000-000. Rel. Eugênio Augusto Clementi Júnior, j. em 05.12.2007).

Os testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas,

denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado, e isso está suficiente demonstrado pela prova carreada aos autos.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava na sua residência, de onde retirava parte para a venda a terceiro, enquanto a maior parte ficava escondida na residência. Fazia da residência de sua genitora, um ponto de revenda a usuários e quiçá a fornecedores. Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP

10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e ainda manter uma considerável quantidade guardada e escondida em seu guarda-roupas, e com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, conclui-se que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem.

Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-

2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.[...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE